

1500549-10.2021.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353920/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 22196792 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 5563/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2353920 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500549-10.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-10.2021.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353920/2021 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 22196792 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 5563/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO,

2353920 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EMERSON DIAS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

Inadmissibilidade no processo de prova obtida por meio ilícito e inviolabilidade domiciliar. Superação de pretérito entendimento jurisprudencial relativo ao flagrante em crime permanente. Novel entendimento pacificado no STF e STJ, exigente de justa causa. Ausência de justa causa e de comprovação de autorização para ingresso na casa. Parcial ilicitude da prova, relativa à apreensão da maconha, que não conduz à improcedência da ação penal. Não incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Fatos autônomos e fontes probatórias independentes. Pequena divergência de testemunhos que, concretamente, não fragilizam suas credibilidades.

Prova do tráfico em relação à cocaína. Procedência da ação penal.

I - Relatório

EMERSON DIAS DA SILVA e RAFAEL MANOEL DOS ANJOS foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 17h40min, na Rua Antônio Augusto Palhares, nº 250 e na Rua Abílio Bernardino de Souza, nº 223, ambos neste município e Comarca de Assis, guardavam, tinham em depósito e vendiam, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 03 (três) porções de Tetrahydrocannabinol (maconha), pesando aproximadamente 53,21g (cinquenta e três gramas e duzentos e dez miligramas), e mais 09 (nove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,7g (seis gramas e setecentos miligramas), substâncias que causam dependência psíquica.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares receberam informações que havia comércio de drogas em um bar, situado no endereço acima descrito, e o entorpecente estava dentro da "máquina de cartão".

Então, deslocaram-se até o local e realizaram "campana" nas proximidades, e puderam visualizar pessoas aproximando-se e falando com RAFAEL e entregando algo a ele, e este ia até EMERSON, que por sua vez entregava para RAFAEL e este entregava "algo" para os terceiros.

Ato contínuo, os policiais entraram no bar, gerenciado por EMERSON, e localizaram dentro da "máquina de cartão" porções de cocaína. Na posse de EMERSON encontraram um aparelho celular e R\$ 1.814,00 (um mil e oitocentos e quatorze reais), em dinheiro, e com RAFAEL outro aparelho celular.

Indagado, EMERSON admitiu que tinha mais entorpecentes em sua residência.

Os réus foram notificados (fls. 212 e 214) e apresentaram defesas prévias (fls. 234/235 e 274/275). Rejeitada estas, a denúncia foi recebida (fls. 284/285). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas (fls. 367) e interrogados os réus.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Considerando a narrativa contida na denúncia e a prova produzida sob o crivo do contraditório, percebe-se que as drogas, objetos e valores indicados no auto de exibição e apreensão foram apreendidos em momentos e lugares distintos: a apreensão da cocaína, parte do dinheiro e a máquina de cartão de crédito foram apreendidos no bar, ao passo que a apreensão da maconha, da balança de precisão e da outra parte do dinheiro ocorreu na casa do correu Emerson.

Determinar o que se apreendeu em cada local se faz imprescindível, porque, como se vê, um dos argumentos invocados pela D. Defesa do corréu EMERSON é ilicitude da prova, que teria sido obtida mediante violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, diferentemente do alegado pelos Policiais Militares, o ingresso na casa dele não foi autorizado (fls. 386/397).

Pois bem.

É consabido que entre as garantias individuais fundamentais figuram inviolabilidade domiciliar e inadmissibilidade, no processo, de provas obtidas por meios ilícitos.

Em relação à inviolabilidade do domicílio, o texto constitucional fez expressa ressalva a algumas peculiares situações, a exemplo da (I) ordem judicial fundamentada e escrita (durante o dia), do consentimento do morador (a qualquer momento) e do flagrante delito (a qualquer momento).

No tocante ao flagrante delito, cabe consignar que, por muito tempo, prevaleceu na jurisprudência a orientação segundo a qual o encontro de drogas no interior da casa conferia legitimidade ao ingresso não precedido de autorização judicial ou de consentimento do morador, sendo lícita a prova assim obtida.

Isso porque o tráfico de droga, em algumas de suas condutas nucleares, como "guardar" e "ter em depósito", é crime permanente, já que sua consumação se protraí no tempo. Por conseguinte, enquanto a droga estiver sendo guardada ou mantida em

depósito, o crime estará sendo praticado e o encontro da droga caracteriza a situação de flagrante.

Porém, entendendo que essa orientação tornava demasiadamente frágil a garantia da inviolabilidade domiciliar, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma virada jurisprudencial, fixando que "para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito". Também cuidando dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o ingresso em casa habitada sob o fundamento de que houve prévia autorização do morador somente será válido e preservará a idoneidade da prova assim obtida se a anuência do morador estiver documentada, cabendo ao Estado o ônus da prova do consentimento do morador e de sua efetiva voluntariedade.

No caso em tela, constata-se que os policiais militares diligenciaram no bar do corréu EMERSON, onde encontraram uma porção de cocaína, uma máquina de cartão de crédito e certa quantia em dinheiro. Na sequência, encaminharam-se para a casa dele, onde localizaram e apreenderam maconha, balança de precisão e a quantia de aproximadamente R\$ 3.000,00 (três mil reais). Segundo os militares, ainda no bar, Emerson lhes teria declarado que guardava drogas em casa e os teria levado ao local, autorizando-lhes o ingresso em sua residência.

Analisando a apreensão ocorrida na casa do corréu Emerson, observo, em primeiro lugar, que o encontro de droga no bar não se presta como justa causa para o ingresso na casa do réu, que, inclusive, ficava em local distante do estabelecimento comercial.

Em segundo lugar, pondero que, embora não se possa legitimamente falar-se em violação à garantia da inviolabilidade domiciliar na hipótese em que o ingresso na casa se dê com prévia assentimento do morador, fato é que, no caso sob exame, nenhuma prova se produziu quanto à alegada autorização. De fato, não se carreteou ao processo sequer uma singela declaração escrita, subscrita pelo morador.

Além disso, os réus infirmam veementemente a alegada autorização, afirmando que os policiais pegaram um chaveiro onde estavam a chave do carro e da casa de Emerson e se deslocaram até à residência, onde ingressaram sem consentimento.

Portanto, nesse quadro e em observância à tranqüila orientação jurisprudencial acima mencionada, declaro a ilicitude e imprestabilidade da prova no que concerne à droga apreendida na casa do corréu Emerson, a qual, por tal razão, é inábil à formação do convencimento deste julgador acerca do crime de tráfico de drogas.

Todavia, a ilicitude da prova no que concerne à apreensão de maconha na casa do corréu Emerson não contamina as demais provas, que dela são independentes, pois seriam obtidas mesmo que os policiais não tivessem ingressado na casa.

Com efeito, a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15 - no que se refere à cocaína), fotografias (fls. 39/40, que se referem à cocaína) e laudos toxicológicos (fls. 147/149, 151/153 e fls. 154/156, tudo apenas no que concerne à cocaína).

Assim, resumidamente, não resta dúvida de que ocorreu apreensão de substância no bar de Emerson, a qual a perícia demonstrou tratar-se de cocaína.

Por outro lado, a autoria recai sobre ambos imputados.

É verdade que, ao ser interrogado, Rafael declarou que a cocaína apreendida era de sua propriedade e que o corréu sequer tinha conhecimento de que ele estava guardando a droga naquele local. Disse ainda que, naquele dia, o bar tinha sido aberto há pouco tempo e não tinham atendido a nenhum cliente.

Por sua vez, Emerson afirmou que a maconha encontrada em sua casa era para seu consumo pessoal, mas nada sabia sobre a cocaína encontrada no bar, na máquina de cartão de crédito.

Entretanto, tais versões restaram infirmadas pelos depoimentos dos policiais.

Com efeito, os policiais militares Victor Luís Santos e Vinicius Rodrigues Torniche informaram, em uníssono, que estavam em patrulhamento, quando receberam informação de que no bar localizado no local dos fatos estaria ocorrendo o tráfico de drogas: a droga estaria escondida em uma "maquininha" de passar cartão de crédito. Foram

até o referido estabelecimento e permaneceram em campana. Observaram a movimentação a uma distância segura. Visualizaram, por três vezes, pessoas indo até o local, falavam com RAFAEL e lhe entregavam "algo", e RAFAEL ia até EMERSON, que também lhe entregava "algo". Por fim, RAFAEL entregava esse "algo" aos terceiros interessados. Após a terceira visualização, foram até o bar e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O policial Victor localizou, dentro da "maquininha" de cartão de crédito, no local destinado à bobina de papel, 09 (nove) pequenas porções de Cocaína. Com EMERSON, foi localizado um aparelho celular Samsung e R\$ 1.814,00 (um mil e oitocentos e quatorze reais), em espécie. Com RAFAEL, foi apreendido um aparelho celular Motorola. Questionado sobre drogas na residência, EMERSON afirmou aos policiais que tinha 30g (trinta gramas) de maconha em uma geladeira. Deslocaram-se até a casa de EMERSON e apreenderam a droga, que estava na geladeira desligada, dividida em 03 (três) porções, pesadas posteriormente em 51,63g (cinquenta e uma gramas e sessenta e três miligramas). Além disso, em uma caixa amarela de papelão, localizaram uma balança de precisão e mais R\$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), em dinheiro.

É certo que não existe prova que goze de presunção absoluta de veracidade, o que, inclusive, contrariaria as funções do processo penal, como instrumento de garantia e de elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório.

Entretanto, ao que se vê, as diligências policiais foram precedidas de informações dando conta da prática do crime de tráfico de drogas, tendo os policiais, em observação, visualizado os réus em atuação conjunta.

Ademais, a localização da cocaína se deu no local exato da denúncia, além de que a forma como estava acondicionada a cocaína (em porções já prontas para venda) e a expressiva quantia em dinheiro encontrada na posse do correu Emerson, ainda no bar, sem comprovação da origem lícita, corroboram a versão dos policiais militares.

De fato, a quantia de R\$ 1.814,00 (mil oitocentos e quatorze) Reais pode ser considerada elevadíssima, especialmente quando se considera que, segundo Emerson, seria fruto de sua atividade empresarial desempenhada no seu pequeno comércio de bairro, que vende mercadorias de pouco valor.

Chama ainda a atenção o fato de que, como afirmado pelos corréus, o bar tinha sido aberto há pouco tempo e não tinham atendido a nenhum cliente, o que torna ainda pouco crível a licitude da procedência de tal quantia e, por via de consequência, acaba por corroborar a versão dos policiais militares.

Pondero que divergências podem possuir maior ou menor relevância para efeitos de credibilidade de testemunhos de pessoas que presenciaram e/ou ouviram os mesmos fatos. Isso porque, como cediço, vários fatores interferem na captação, retenção e comunicação dos fatos presenciados, sendo até mais natural a ocorrência de pequenas divergências do que a absoluta convergência entre diferentes testemunhas.

No caso em apreço, reputo de somenos importância a circunstância de um policial militar ter afirmado que o informante havia falado da venda cocaína enquanto outro ter dito que a venda era de droga. O uso alternativo da palavra droga ou cocaína poderia ganhar contorno de maior relevância se ambos tivessem visto a droga e cada qual dissesse coisas distintas e não fossem capazes de esclarecer o motivo do uso alternativo dos termos. Porém, não é essa a realidade.

Ademais, também a circunstância de os policiais não terem dito com precisão qualquer era o objeto das trocas realizadas entre os réus e as pessoas que ali compareciam não é suficiente para suscitar dúvida se se tratava ou não de droga. Isso porque a substância foi encontrada no local, na linha da informação antes obtida, ao que se soma a apreensão de expressiva quantia em dinheiro naquele exato momento da prisão.

Por fim, até reputo admissível que se critique a ausência de providência dos policiais militares para promover a identificação das pessoas visualizadas na operação de entrega e recebimento por eles declaradas. Contudo, frente as já enunciadas peculiaridades do caso concreto, reputo que dessa deficiência não decorre a insuficiência do conjunto probatório para alicerçar o decreto condenatório pelo crime de tráfico em relação a ambos corréus.

Dessa forma, considerando-se que os acusados incidiram em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo

excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

a) EMERSON DIAS DA SILVA:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que o sentenciado ostenta maus antecedentes (processo 0007682-41.1995.8.26.0047, tráfico de drogas - fls. 311; processo 0013625-87.2005.8.26.0047, estelionato, 1ª Vara Criminal de Assis - fls. 313/314; processo 0018827-40.2001.8.26.0482, receptação, 2ª Vara Criminal de Presidente Prudente - fls. 315/316). Por se tratar de três condenações, elevo a pena-base em 1/4 e a fixo em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Verifica-se que o sentenciado é reincidente (processo 0000102-32.2010.8.26.0047, da 1ª Vara Criminal de Assis - fls. 311; processo 0012351-15.2010.8.26.0047, tráfico de drogas, 2ª Vara Criminal de Assis - fls. 312/313), o que autoriza a majoração da pena em 1/4. Não há atenuantes. Assim, a pena intermediária perfaz o total de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, além de 781 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Ressalto que não se aplica o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Portanto, torno definitiva a pena de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, além de 781 dias-multa.

b) RAFAEL MANOEL DOS ANJOS:

Na primeira fase, em análise às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, observada a Súmula 444 do STJ e o entendimento dos Tribunais Superiores que a condenação pelo art. 28, da Lei de Tóxicos, não configura maus antecedentes ou reincidência. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de forma que a pena intermediária permanece inalterada e idêntica à pena-base.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Por outro lado, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque não há prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha envolvimento com organização criminosa ou se dedique a tais atividades, valendo salientar que inexistente qualquer prova de que os corréus estariam vendendo drogas com alguma habitualidade, de sorte a caracterizar o exercício de atividade, razão pela qual a presunção que milita a seu favor é de que aquele foi um ato isolado.

Assim, e tendo em vista a pequena quantidade de cocaína apreendida (única droga apreendida licitamente), a pena deve ser reduzida em sua fração máxima, ou seja, 2/3, razão pela qual fixo a reprimenda final, para o réu RAFAEL, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis dias multa) dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

a) EMERSON DIAS DA SILVA ao cumprimento de 7 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, além de 781 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006;

b) RAFAEL MANOEL DOS ANJOS ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Regime inicial de cumprimento de pena: com relação a EMERSON, tendo em vista a quantidade da pena fixada, maus antecedentes e reincidência, o regime será o fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea a, do Código Penal.

Já no que tange ao corréu RAFAEL, como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o

regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.C § 3º do mesmo artigo. Diante disso, com relação ao réu RAFAEL, o regime inicial será o aberto.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível para EMERSON, uma vez que a pena suplanta 4 anos e é reincidente.

Já com relação a RAFAEL, considerando que não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis, substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: incabível para todos os réus em razão da quantidade de pena aplicada.

Objetos apreendidos: determino o perdimento dos bens e valores apreendidos, eis que desprovidos de valor econômica e possuem relação com o delito praticado, com exceção do celular com o qual não foi realizada a perícia, que deverá ser restituído. Oficie-se ao FUNAD.

Prisão preventiva: com relação ao sentenciado EMERSON, os motivos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar foram robustecidos com a presente condenação. Pr tal motivo, recomende-o à unidade prisional na qual se encontra.

Por outro lado, no que atine ao corréu RAFAEL, tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, não se justifica a manutenção da prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de RAFAEL MANOEL DOS SANTOS.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA